

1500099-41.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. 1. NULIDADE. (...) VÍCIO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO QUE NÃO SE TRANSMITE PARA A AÇÃO PENAL. (...) 3. Os vícios ocorridos na primeira fase da persecução não maculam nem inviabilizam o exercício da ação penal. Isto porque o inquérito policial é peça meramente informativa, na qual não se produzem provas, mas apenas são amealhados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500099-41.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500099-41.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2014614/2021 - 1º Distrito Policial de Lorena, 15713638 - 1º Distrito Policial de Lorena, 61/21/204 - 1º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

VITOR DANIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS e outro

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de VITOR DANIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, na qual lhe é atribuída a prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e 244-B, da Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e Adolescente - ECA, pelos fatos narrados na denúncia de fls. 80/82.

A denúncia foi recebida em 04/02/2021 (fls. 83/84). O réu foi dado por citado (fls. 122), apresentando resposta à acusação (fls. 152/153). Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 154).

Durante a instrução processual foram ouvidas vítimas e testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado. Na sequência, as partes apresentaram as suas alegações finais, por

meio de memoriais.

O Parquet pugnou pela procedência integral da ação penal, com a condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 208/221).

Por seu turno, a defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade do auto de prisão em flagrante, por conta da "ausência da autoridade policial nos procedimentos". No mérito, pugnou pela absolvição, em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou pelo reconhecimento do concurso formal de crimes; a aplicação da pena no mínimo legal, com a atenuante da menoridade relativa; e a fixação do regime inicial mais brando para o crime tipificado no ECA (fls. 226/235).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, rechaço a preliminar de nulidade do auto de prisão em flagrante.

Bem se sabe que eventuais falhas ou lapsos existentes durante o inquérito policial não passam de meras irregularidades, não possuindo condão de contaminar a ação penal nele baseada. Portanto, ainda que a autoridade policial não tenha presidido o auto de prisão em flagrante no caso concreto, sob a ótica processual, tal circunstância não nulifica a presente ação penal.

Nesse sentido:

"SENTENÇA CONDENATÓRIA (...) - PRELIMINAR - NULIDADE NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - AUSÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL NO INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS - ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - (...) PRELIMINAR - NULIDADE AFASTADA - INIQUOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO INTERROGATÓRIO REALIZADO NA FASE ADMINISTRATIVA - INQUÉRITO POLICIAL - PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA - PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA COM OBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS ACUSADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (...) - RECURSOS DESPROVIDOS, OBSERVADA A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL". (TJSP; Apelação Criminal 0000397-12.2016.8.26.0483; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Presidente Venceslau - 2ª Vara; Data do Julgamento: 23/06/2017; Data de Registro: 28/06/2017).

Mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. 1. NULIDADE. (...) VÍCIO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO QUE NÃO SE TRANSMITE PARA A AÇÃO PENAL. (...) 3. Os vícios ocorridos na primeira fase da persecução não maculam nem inviabilizam o exercício da ação penal. Isto porque o inquérito policial é peça meramente informativa, na qual não se produzem provas, mas apenas são amealhados elementos informativos com o objetivo de dar suporte ao órgão acusador para eventual oferecimento de denúncia. - Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial não contaminam a ação penal. Precedentes: AgRg no HC n. 549.109/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019 e RHC n. 112.336/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 2/12/2019. 4. Este Tribunal assentou entendimento no sentido de ser essencial à alegação de nulidade a demonstração do prejuízo. Neste caso, a defesa argumenta que não foi observado o rito previsto no art. 55 da Lei de Drogas, mas falha ao expor de que maneira esse fato teria sido prejudicial ao exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, de modo que não se pode reconhecer tal nulidade, pois a teor do art. 563, mesmo as nulidades absolutas não dispensam a demonstração do efetivo prejuízo, pelo princípio do *pas de nullité sans grief*. - A propósito: RHC n. 94.446/MS, Rel.

Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 25/5/2018 e AgRg no AREsp n. 1341923/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 17/12/2018. (...) 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 533.358/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (Sublinhados meus).

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/03); boletim de ocorrência (fls. 04/08); autos de reconhecimento pessoal (fls. 14, 16, 17 e 18); auto de exibição e apreensão (fls. 20); auto de entrega (fls. 21/22); bem como pelas provas orais.

O mesmo se pode dizer em relação à prova de autoria, conforme se verá a seguir.

A vítima Rita de Cássia Belvilaqua de Souza contou que estava na cozinha de sua casa, logo após chegar ao imóvel com seu marido, quando ouviu um barulho, logo percebendo a presença de dois indivíduos: um armado, encapuzado, e outro, de boné e mascarado. A dupla exigiu todo o dinheiro e o celular e, depois de subtraí-los, o mais alto pulou o muro, enquanto o de menor estatura, que portava a arma de fogo, deu um chute no portão e saiu. Questionada, disse que não sabe esclarecer o valor exato subtraído pelos criminosos, estimando que pudesse ser cerca de dois mil e setecentos reais, montante que costuma faturar na feira. Afirmou que ficou muito nervosa, não conseguindo olhar para os rostos dos delinquentes. Narrou que, assim que os dois larâpios saíram, ligou para polícia, que conseguiu captura-los. Confirmou que reconheceu pessoalmente o menor por conta da estatura diminuta conquanto não tenha visualizado seu rosto, mas não o de maior estatura. Por fim, instada a analisar as imagens do acusado, Rita de Cássia não o reconheceu.

Seu esposo, reverberou sua versão. Tal ofendido contou que o dinheiro subtraído estava na posse dos indivíduos abordados pelos policiais, que era cerca de R\$ 1.800,00, embora acredite que o valor subtraído fosse cerca de R\$ 3.400,00 a R\$ 3.500,00, além do celular e cerca de R\$ 400,00, pertencente a sua esposa. Questionado, esclareceu que não reconheceu os ladrões em sede policial. Contudo, disse que o valor recuperado com os bandidos estava no interior do mesmo embrulho que o guardava. Contou que na delegacia encontrava-se apenas o adolescente (menor estatura), enquanto o outro estava no hospital, e que viu apenas os rostos dos criminosos. Afirmou que os policiais militares apresentaram o adolescente em delegacia de polícia na posse de dinheiro. Por fim, o ofendido não reconheceu o acusado como um dos seus algozes.

Já o policial militar Zaqueu contou que estava em patrulhamento de rotina, quando se deparou com dois indivíduos, um mais alto e o outro mais baixo, sendo que ambos, ao perceberem a aproximação da viatura policial, tentaram empreender fuga, alcançando apenas o mais baixo (adolescente W.A.G.D). Narrou que o seu colega de farda continuou no encalço do outro indivíduo com a viatura, vindo a saber depois que se tratava do acusado, que foi capturado e reagiu a abordagem. Instantes depois, ficou sabendo pelo sistema interno de rádio da corporação que havia acabado de ocorrer um roubo em uma residência em local próximo, cujos roubadores ostentavam as mesmas características físicas do réu, e do adolescente. De acordo com o agente público, o menor confessou informalmente sua participação no roubo, indicando terceira pessoa envolvida na ação criminosa (Wagner), já conhecido dos meios policiais. O adolescente também disse que parte do dinheiro e a arma do crime ficou com Wagner. Zaqueu afirmou, também, que as vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, o adolescente, de modo presencial, e o réu, por meio de fotografias.

Seu companheiro de farda, Marcos Vinicius Guatura Tobias Lima fez eco às suas palavras.

Essa, portanto, a prova oral.

Pois bem. Malgrado as vítimas não tenham reconhecido o acusado em juízo, existem outros elementos probatórios que o compromete.

Primeiro, o réu foi encontrado na posse de parte da "res furtiva", uma vez que as vítimas reconheceram a embalagem (pacote) em que se encontrava o dinheiro recuperado. Note-se que o acusado foi surpreendido pelos policiais militares poucos minutos após a subtração, tanto que esses agentes da lei sequer tinham conhecimento do roubo em assunto.

Segundo, a reação do réu e seu comparsa. Como se viu dos depoimentos dos agentes da lei, tanto Vítor Daniel quanto o menor ficaram nervosos com a aproximação da viatura policial e tentaram fugir, comportamento este, no mínimo, suspeito.

Nesse sentido, o entendimento recente do E. Tribunal de Justiça deste estado:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS - (...). Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Réus presos na posse da res furtiva. Inversão do ônus da prova. Majorantes comprovadas. (...) Recurso parcialmente provido". (TJSP; Apelação Criminal 0004074-43.2015.8.26.0238; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibiúna - 1ª Vara; Data do Julgamento: 31/01/2022; Data de Registro: 31/01/2022); e

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DOS OFENDIDOS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas no decorrer da instrução - Depoimentos das vítimas e de policiais aos quais se confere relevante valor probatório - Reconhecimento efetivado pelos ofendidos em solo policial que reforçam a certeza da autoria - Reconhecimento em eventual inobservância de formalidade prevista no art. 226 do CPP que não macula a prova - Sentença que se baseou em outros sólidos elementos de convicção, e não somente no reconhecimento dos acusados - Ausência de demonstração de efetivo prejuízo - Inteligência do art. 563, do CPP - Negativas de autoria que restaram isoladas no acervo probatório - Ausência de comprovação dos ventilados alibis - Apreensão da 'res furtiva' em poder dos acusados - Inversão do ônus da prova - Devidamente comprovado, ainda, que o delito fora cometido em comparsaria, mediante utilização de arma de fogo (apreendida nos autos, malgrado inoperante, o que ensejou o afastamento da referida causa de aumento de pena) e restrição de liberdade dos ofendidos - Desclassificação da imputação para receptação - corréu Thiago - Descabimento - Comprovação de que o acusado, de fato, participou do roubo narrado na denúncia - Ausência de comprovação do alegado pelo réu - Condenações mantidas - (...) Recursos desprovidos". (TJSP; Apelação Criminal 0000300-13.2017.8.26.0633; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 1ª Vara; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 29/11/2021) (Sublinhados meus).

Além disso, conforme as palavras das vítimas, que não têm qualquer interesse em prejudicar pessoas que sequer conheciam antes dos fatos delituosos, dois eram os criminosos, cujas características coincidiram com as do réu, e a do menor (W.A.G.D). Não por outro motivo, os policiais militares, após terem abordados o acusado e o adolescente, levaram-nos para o distrito policial, local onde as vítimas os reconheceram.

E tem mais: o próprio réu confessou sua participação no crime durante seu interrogatório policial, prestado na presença de seu advogado (fls. 23), narrando seu papel na empreitada criminosa, com riqueza de detalhes, em linha com a narrativa apresentada pelas vítimas em pretório.

Saliente-se não ser defeso a este Magistrado, utilizar elementos informativos produzidos no curso de inquérito policial, como expostos nos parágrafos anteriores, por exemplo, os interrogatórios dos réus e as declarações da informante judicial perante a autoridade policial e o relatório de investigação, na medida em que tais elementos foram corroborados com as provas produzidas em juízo, como neste caso, quando apreciados os depoimentos daqueles agentes estatais durante a instrução criminal destes autos.

Na prática, o desprezo ao que se produziu na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em nosso ordenamento. Ainda que tenha, a princípio, menor valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, como fundamentado acima, não pode tal ser afastado de pronto.

Significa dizer, a prova deve ser vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida, mas o valor probante, estando preservados os direitos constitucionais dos réus, o que foi garantido por este Juízo, no acompanhamento de todas as provas produzidas em sede judicial, inclusive que acabaram por confirmar a versão acusatória apresentada em fase inquisitiva.

Nesse sentido caminha a jurisprudência:

“APELAÇÃO – (...) – Validade dos testemunhos policiais como meio de prova, ausentes indícios de que queiram prejudicar o adolescente – Alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal – Inocorrência – Elementos informativos que, quando corroborados por provas produzidas sob as garantias do contraditório, podem constituir a formação da convicção do julgador – Precedentes – Referida norma processual que somente veda a utilização exclusiva dos elementos de informação para justificar a condenação, o que não é o caso dos autos – (...) – Apelação não provida”. (TJSP; Apelação Cível 0001078-47.2018.8.26.0180; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020); e

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO APOIADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O art. 155 do Código de Processo Penal não veda, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial. Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do agravante se lastreou em provas produzidas em juízo, notadamente a versão apresentada por uma das vítimas, corroboradas por elementos colhidos na fase policial, não havendo nulidade a ser reconhecida. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ; AgRg no HC 378640/SP; Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro; Órgão julgador: Sexta Turma; Data da publicação: 01/10/2018) (Grifamos).

Portanto, de acordo com a palavra dos agentes da lei e das vítimas em juízo, as quais ratificaram a confissão pré-processual do réu, é fato que Vitor Daniel era um dos roubadores.

Ao seu turno, considerando que os fatos ocorreram após a alteração legal da Lei 13.654/18, as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I do Código Penal, consistentes no concurso de agentes e na utilização de

arma de fogo para o emprego da ameaça, respectivamente, devem ser reconhecidas, pois assim caminhou a prova oral.

Com efeito, indiscutível que quando mais de um agente se une para a prática do crime, isso aumenta a chance de sucesso da empreitada e, no caso, eram dois os agentes delituosos, ainda que o comparsa do acusado fosse menor de idade à época dos fatos.

Confira-se igual posicionamento da jurisprudência do nosso E. Tribunal:

“DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL - PROVAS VÁLIDAS. As declarações da vítima e o reconhecimento pessoal, ratificado em juízo, são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio, quando seguros e em sintonia com os demais elementos probatórios. CONCURSO DE AGENTES CARACTERIZADO AINDA QUE O COAUTOR SEJA MENOR. QUALIFICADORA APLICABILIDADE. Aplica-se a qualificadora do concurso de agentes ainda que o outro integrante seja menor inimputável, posto que a proteção penal volta-se contra a maior gravidade representada pela ação conjunta, sendo irrelevante a inimputabilidade do coautor. ROUBO - ARMA DE FOGO AUSÊNCIA DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. É prescindível a apreensão da arma de fogo, para configuração da causa de aumento, quando os depoimentos das vítimas são peremptórios quanto a sua utilização pelo agente”. (TJSP; Apelação Criminal 9235696-82.2008.8.26.0000; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2011; Data de Registro: 02/03/2011); e

“Apelação. Roubo majorado por concurso de agentes. (...) Sentença condenatória. Insurgência defensiva. (...) Restou evidenciado, pois, que o apelante, juntamente com um comparsa não identificado, abordou a vítima em uma ciclovía e anunciou o assalto. (...) Majorante sobejamente demonstrada (concurso de pessoas). Não há falar em participação de menor importância na espécie, pois o réu praticou o delito em conjunto com o comparsa desconhecido, mediante a utilização de uma bicicleta de propriedade do apelante, empregando atos de violência contra a vítima e logrando êxito na subtração do bem (...) Recurso defensivo improvido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500889-23.2020.8.26.0536; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/09/2021; Data de Registro: 29/09/2021) (Ênfases minhas).

De igual modo, a utilização de arma de fogo é incontestável, posto que as duas vítimas apontaram a existência do armamento.

Anoto que a falta de apreensão da arma não impede o reconhecimento dessa causa de aumento, comprovada pela prova oral produzida, em consonância com a jurisprudência, já pacífica neste sentido:

“(...) De início, registra-se que 'consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)' (HC 336.545/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 09/08/2016). A corroborar esse posicionamento: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO I DO CP. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou o entendimento no sentido de que para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o

seu efetivo emprego na prática delitiva (Eresp n. 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza da arma de fogo, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no RESp 1.582.127/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 10/6/2016). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. SÚMULA 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas. [...] 3. Agravo regimental improvido". (STJ; AgRg no RESp 1577315/MG, Relator: Ministro Nefi Cordeiro; Órgão Julgador: Sexta Turma; Data da publicação: 28/06/2016) (...)" (STJ; RESp: 1415857/SP 2013/0364647-5, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Publicação: 17/11/2016) (Grifos nossos).

Com relação ao crime de corrupção de menor, do artigo 244-B, da Lei 8.069/90 - ECA, o caso também é de condenação, por se tratar de crime formal, uma vez comprovada a atuação do adolescente W.A.G.D., conforme os depoimentos das vítimas, das testemunhas e do próprio acusado, este último em sede policial.

Destarte, sendo o fim precípua dessa norma penal obstar que os delitos em geral sejam praticados na companhia de menor de idade, independentemente de se tratar de agente já corrompido, ou não, de qualquer modo, de rigor a sua condenação pelo crime tipificado no artigo 244-B, da lei acima citada, acompanhando-se a jurisprudência resistente e sumulada sobre o assunto.

Neste ponto, ainda que não levantado pela defesa, ressalto que a condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes, como configurado nestes autos e acima fundamentado, e a corrupção de menores não implicam em bis in idem, dado que o primeiro delito se tutela o patrimônio e o bem jurídico tutelado neste último crime é a integridade moral do menor de 18 anos, de modo que se trata de delitos autônomos.

Nesse sentido é o entendimento do nosso E. Tribunal, há tempos e em julgado recente:

"Apelação da Defesa - Furto qualificado pelo concurso de agentes - Provas suficientes à condenação - Prisão em flagrante em poder do bem subtraído - Consistentes depoimentos do guarda civil municipal - Negativa do acusado não comprovada - Qualificadora bem demonstrada pela prova oral - Corrupção de menor - Delito de natureza formal, bastando à consumação que a criança ou o adolescente participem da empreitada criminosa - Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça - Reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes, em relação ao furto, que não acarreta "bis in idem" - Crimes autônomos e que tutelam bens jurídicos distintos - Condenações mantidas (...) - Regime semiaberto compatível com a hipótese dos autos - Crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa - Súmula 269 do STJ - Recurso de apelação parcialmente provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500025-24.2016.8.26.0536; Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de Registro: 10/01/2020); e

"APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - Crime formal - Desnecessidade de demonstração da efetiva corrupção, bastando a participação do menor na empreitada criminosa, conforme restou configurado, 'in casu', pelas provas amealhadas. Condenação de rigor. RECURSO MINISTERIAL VISANDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES PARA O CRIME DE ROUBO - ACOLHIMENTO - Não há que se cogitar da ocorrência de bis in idem em razão da condenação pelo crime de corrupção de menores e de roubo em concurso de agentes, uma vez que este último se configura pelo simples fato de o roubo ter sido praticado por mais de um agente,

independentemente de sua idade, conferindo maior gravidade ao delito; enquanto o primeiro se caracteriza pela participação específica de criança ou adolescente em infrações penais, a fim de punir o agente que corrompa ou facilite a corrupção de menores, a quem a lei dá especial proteção. Condutas autônomas, previstas em tipos penais diferentes, com finalidades e bens jurídicos tutelados distintos. Recurso da Defesa não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido, para reconhecer a causa de aumento do concurso de agentes para os crimes de roubo". (TJSP; Apelação Criminal 1501065-47.2020.8.26.0618; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 18/02/2022) (Sublinhado na reprodução).

Portanto, passo a dosimetria das penas.

a) Crime do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Estatuto Repressivo:

O réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes, conforme certidão de objeto e pé de fls. 203.

Contudo, considerando que as vítimas suportaram prejuízo, na medida em que grande parte do dinheiro e o celular não foram recuperados, hei por bem fixar a pena-base em 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal, ou seja, em 04 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da menoridade relativa, artigo 65, inciso I, do Código Penal, e da confissão espontânea, do mesmo artigo e Código, mas, inciso III, alínea "d", retornando, assim, as sanções ao piso (04 anos de reclusão e 10 dias-multa), por não ser possível estabelecê-las abaixo desse mínimo, conforme jurisprudência sumulada.

Súmula 231, do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase, à vista da causa de aumento do § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal (comparsaria), elevo-a as penas em 1/3 (um terço), ao patamar de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Ainda nesta etapa, reconheço a outra causa de majoração das sanções, prevista no § 2º-A, inciso I, do mesmo artigo e Código (uso da arma de fogo), no caso, pelo próprio réu, segundo as provas dos autos, agora, na fração de 2/3 (dois terços), aumentando-as, em definitivo, em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, por inexistirem outras circunstâncias modificadoras.

Forçoso apontar que mesmo antes da alteração trazida pela Lei 13.654/2018, permitia-se a cumulação da causa de aumento de emprego de arma de fogo com quaisquer das demais majorantes legalmente previstas no § 2º, do artigo 157, do Código Penal, e o que pretendeu a nova lei foi conferir as esses delitos, praticados com utilização de arma de fogo, tratamento mais severo, a fim de compatibilizar com a gravidade peculiar advinda de tal circunstância.

Ora, seria um contrassenso ignorar a existência de outras causas de aumento de pena, aplicando-se apenas uma delas, quando a nova lei, neste caso, a individualizou e aumentou a razão do acréscimo à sanção, quando perfeitamente cumuláveis, forte na possibilidade do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

Nessa toada, tem-se o entendimento das Cortes Superiores:

"(...) Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. Não pode ser automática. Isso porque o Código Penal diz, tanto no parágrafo único do art. 68, como no § 2º do art. 157, "pode o juiz" e "aumenta-se de 1/3 até metade", indicando claramente, que a opção do magistrado há que ser fundamentada, sob pena de se transmutar a discricionariedade permitida com um inaceitável arbítrio próprio do princípio da convicção íntima. Na hipótese, verifica-se que a exasperação da pena foi devidamente fundamentada, lastreando-se no fato do crime ter sido cometido mediante emprego de arma de fogo, em consonância com o parágrafo 2º-A inciso I do art. 157, do Código Penal. (...)". (STJ; HC 579941, Relator: Min. Felix Fischer; Decisão monocrática; Data da Publicação: 14/08/2020); e

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. [...] 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. [...] 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual". (STF; HC 110.960/DF; Rel. Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: Primeira Turma; Data da Publicação: 24/09/2014) (Sublinhados na reprodução).

Não sendo outra a posição da jurisprudência recente do nosso E. Tribunal:

"Apelações Criminais – Roubo bimajorado pelo "concurso de agentes" e "emprego de arma de fogo" (artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal) – (...) Majorantes dos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do C. Penal que devem ser igualmente consideradas no cálculo das reprimendas, até porque o § único do art. 68 desse diploma repressivo confere ao juiz apenas a faculdade de aplicar somente uma causa de aumento ou diminuição – Alterações legislativas operadas pelas Leis nºs 13.654/2018 e 13.964/2020 que evidenciam o propósito do legislador de agravar as consequências jurídico-penais em relação aos autores de roubos majorados. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial parcialmente provido, nos termos do acórdão". (TJSP; Apelação Criminal 1516127-70.2019.8.26.0228; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/02/2021; Data de Registro: 04/02/2021) (Ênfases nas reproduções).

b) Crime do artigo 244-B, da Lei 8.069/90:

Assim como exposto na dosimetria do crime anterior, o acusado ostenta bons antecedentes, não sendo desfavoráveis as demais circunstâncias judiciais. Logo, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda etapa, reconheço as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, contudo, sem alterações, tendo em vista a inteligência da súmula 231, do C. STJ, anteriormente citada.

Por fim, não havendo causas de aumento e diminuição de pena, fixo em definitivo a pena acima lançada.

Anoto que os delitos em questão são resultantes de desígnios autônomos, de espécies distintas, com elementos subjetivos e objetivos diferentes, que tutelam bens jurídicos diversos e momento consumativo próprio. Logo, a hipótese é de concurso material (artigo 69, do Código Penal).

Ademais, o concurso formal, como requerido pela defesa, importaria em prejuízo ao acusado, vez que a pena do crime mais grave elevada em 1/6 (um sexto), fração mínima prevista na lei, excederia a que seria cabível pela regra do artigo 69, do Código Penal, forte no parágrafo único, do artigo 70, do código citado.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Roubos majorados pelo concurso de agentes, sendo um consumado e outro tentado. (...). Corrupção de menores. Concurso material. (...) Mantém-se o reconhecimento do concurso material com o crime de corrupção de menores, por tratar-se de medida mais benéfica para o réu. Regime inicial fechado de rigor. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500268-43.2021.8.26.0228; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 25/01/2022) (Sublinhado na reprodução).

Portanto, as penas devem ser somadas, resultando em uma pena final de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa.

Diante de roubo duplamente circunstanciado, em concurso de crimes, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, à vista do montante de pena aplicado, forte no artigo 33, §§ 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Confira-se:

“Roubo circunstanciado – Quadro probatório harmônico e coeso – Condenações decretadas. Regime prisional – Circunstâncias do episódio e quantum final das penas que justificam a fixação do regime mais gravoso. Apelo acusatório provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1501984-28.2019.8.26.0050; Relator (a): Mauricio Valala; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/10/2021; Data de Registro: 04/10/2021).

Por fim, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, com base no salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do increpado.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar VITOR DANIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, em concurso material, do artigo 69, do Código Penal, a uma pena total de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 21 (vinte e um) dias-multa, diária mínima, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, tampouco

cabível a suspensão condicional da reprimenda, considerando o montante da reprimenda aplicada e por se tratar de crime cometido com grave ameaça, forte nos artigos 44, incisos I, e 77, "caput", ambos do Código Penal.

Concedo-lhe, entretanto, o direito de recorrer em liberdade, por encontrar-se nessa situação, conforme decisão de fls. 195/196, que revogou a prisão preventiva do réu, não existindo qualquer motivo ponderoso à decretação de sua custódia preventiva, mesmo agora após sua condenação.

Custas pelo vencido.

Intimem-se as vítimas desta sentença.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se mandado de prisão e, com o cumprimento, a guia de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhadas de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; e d) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se com baixa.

P.I.C

Lorena, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA